

1509197-31.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... em unidades, para fins de tráfico.

Relata a inicial que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, policiais civis, que diligenciavam visando prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes no local, se depararam com o indiciado em atitudes suspeitas, razão pela qual deliberaram abordá-lo, ocasião em que vieram a encontrar em seu poder as já citadas drogas, no interior da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509197-31.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509197-31.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação
de Prisão em Flagrante - 2106005/2022 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 24381488 - 100º

D.P. JDIM HERCULANO, 2106005 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JHONATAN DE LIMA MORAIS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JHONATAN DE LIMA MORAIS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 18 de abril de 2022, por volta das 13h00, na Viela Frei Adílson, altura do nº 1, Jardim Ângela, nas imediações de estabelecimento de ensino, nesta comarca e capital de São Paulo, trazia consigo, para entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 64 invólucros contendo cocaína, com massa líquida de 22,7 g; 61, contendo crack, com massa líquida de 7,8 g; 39, contendo maconha, com massa líquida de 40,7 g; e outros 17,

contendo lança-perfume, com volume líquido de 136 ml.

Consta da denúncia que segundo o apurado, na data e local supramencionados, o indiciado trazia consigo, no interior de uma sacola, os citados entorpecentes, divididos e acondicionados em unidades, para fins de tráfico.

Relata a inicial que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, policiais civis, que diligenciavam visando prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes no local, se depararam com o indiciado em atitudes suspeitas, razão pela qual deliberaram abordá-lo, ocasião em que vieram a encontrar em seu poder as já citadas drogas, no interior da sacola que ele trazia junto às mãos.

Narra a exordial que a infração estava sendo praticada nas proximidades da Escola Estadual Professora Amélia Kerr Nogueira, localizada na Avenida dos Funcionários Públicos, nº 1355, nesta urbe.

Ao ser interrogado na fase policial, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 15).

Em audiência de custódia (fls. 41/42), a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 44/47).

A Defensoria Pública impetrou habeas corpus com pedido de ordem liminar, visando, em síntese, a concessão da liberdade em favor do acusado (fls. 55/60). Foram prestadas informações (fls. 64/65).

O acusado foi citado junto ao CDP Osasco I pela ferramenta virtual Teams (fl. 103).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, confesso, sem antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não há qualquer indício a evidenciar que o réu tinha ciência de que estava nas imediações de um estabelecimento de ensino; c) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; d) a outorga de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; e) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal é procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), Auto de exibição e apreensão (fl. 10), Boletim de ocorrência (fls. 11/13), Laudo de constatação (fls. 27/30), Relatório final de inquérito policial (fls. 39/40), Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 104/107), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo de Exame Químico-Toxicológico nº 140616/2022 (fls. 104/107), revelou resultado positivo para as substâncias cocaína (Item 1), tricloroetileno (Item 2), cocaína (Item 3) e tetrahydrocannabinol, conhecida popularmente como maconha (Item 4).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Eduardo Simões de Araújo, policial civil, narrou, em síntese, que o local é muro da escola. Tem a entrada do colégio e uma viela para entrada na comunidade. O réu estava trabalhando ali. Eles ficam no fundo da viela. Não tem ponto de visibilidade para campana, o depoente foi simular compra de entorpecente. O rapaz aqui presente estava sentado atrás de um carro com uma sacola plástica na mão. Iniciou a abordagem. O réu se debateu, resistiu a prisão. Dentro da sacola plástica tinha entorpecentes. O réu estava "fora de si". Na Delegacia ele informou que estava no tráfico, mas não disse quem era o dono da droga.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Israel Simões de Araújo, policial civil, que relatou, em suma, que o local é parede, muro da escola. Na lateral tem uma viela que dá acesso a uma comunidade. Como é um local que não tem como fazer campana, o parceiro foi um pouco mais a frente e o depoente foi atrás. O parceiro viu uma pessoa sentada em uma cadeira atrás de um carro. O parceiro deu voz de abordagem e o rapaz tentou empreender fuga. Cercaram o rapaz, até que conseguiram pegá-la. Ele estava nervoso. Na sacola que o réu portava tinham entorpecentes. Na delegacia ele começou a se acalmar e falou que estava traficando. Todas as crianças e pessoas que frequentam a escola precisam passar por ali.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Em suma, o réu aduziu em juízo que está com 21 anos de idade. Mora com a mãe, esposa, uma filha e seis irmãos. Mora próximo do local onde foi preso, em uma comunidade. Estudou até o primeiro grau. Trabalha de ajudante geral. Estava sim, mas foi por causa de uma dívida na biqueira. Está arrependido. Não vai acontecer mais. É usuário de droga. Era o primeiro dia que trabalhava no tráfico. A dívida do interrogando era de R\$ 750,00. Não foi conversado quantos dias teria que trabalhar. Não pode dar o nome da pessoa, o nome não sabe, vulgo "bolinha".

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis foram uníssonos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais civis quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e variedade das drogas apreendidas (cocaína, crack,

maconha e lança-perfume); b) pela considerável quantidade de drogas (71,2g de massa líquida e 136ml no total), incompatível com a condição de mero usuário; c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas (em invólucros); d) pelas circunstâncias e pelo local da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

A Lei dispõe no citado dispositivo que:

“As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;” (grifos nossos)

A razão da majorante se deve ao fato de que é mais fácil a disseminação do tráfico em local com maior número de pessoas. Guilherme de Souza Nucci, em Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Editora Revista dos Tribunais, comentando este dispositivo, ensina que “quanto maior for a aglomeração de pessoas, mais fácil, ágil e disseminado torna-se a mercancia da droga, razão pela qual se justifica a causa de aumento de pena”.

No presente feito, a prova colhida nos autos fornece elementos a demonstrar que se tratava de local extremamente próximo à Escola Estadual Professora Amélia Kerr Nogueira, localizada na Avenida dos Funcionários Públicos, nº 1355, em São Paulo, segundo o depoimento das testemunhas policiais o Réu foi abordado defronte ao muro da escola, de forma que a majorante restou demonstrada.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme se infere da certidão criminal a fl. 32 e da folha de antecedentes as fls. 75/76. No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea. Deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Em terceira fase de aplicação da pena, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei nº 11.343/2006, em razão de a infração ter sido cometida nas imediações de estabelecimento de ensino, conforme fundamentação, aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Também em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais desabonadores, bem como nada indica que integre organização criminoso ou se dedique a atividades criminosas, de modo

que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, autorizam a redução de 2/3 (dois terços) da pena fixada, culminando com a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, sem antecedentes desabonadores, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade.

Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos)

Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado JHONATAN DE LIMA MORAIS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 194 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 387, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal, verifico não ser o caso de manter a prisão cautelar do réu, considerando a pena aplicada, a fixação do regime inicial aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo ser

facultado o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condene o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 30,00) em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

Comunique-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus de fl. 63, o encerramento da instrução com sentença.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA